

北原鑑定に関する意見書

北原鑑定書の内容・手法の妥当性について論じた意見書。

【年度】－

【税目】－

【手続】意見書

【事件番号】－

【出典】－

【公開用編集】公開用に編集し、必要に応じて匿名化（黒塗り）しています。本文は2ページ目から始まります。

・・高等裁判所平成・年（・・）第・・号
所得税青色申告承認取消処分取消請求事件
原告・控訴人 北原 卓夫
被告・被控訴人 伊那税務署長

鑑 定 書

平成 六年 八月一五日
立命館大学法学部教授（法学博士・一橋大学）

一 鑑定趣旨

伊那税務署署長が昭和六三年三月一日付で行った、北原卓夫に係わる昭和六〇年分以後の所得税青色申告の承認の取消処分の適法性について。

二 結論

伊那税務署は帳簿書類等の備付け状態等を確認するために社会通念上要求される程度の努力を怠っており、承認取消処分は違法といわざるを得ない。

三 理由

（一）本件の争点は、結局のところ、原告・控訴人の帳簿提示拒否が所得税法一五〇条一項の「帳簿書類の備付け、記録又は保存」が法の定めるところに従って行われていない、という青色申告承認の取り消し要件と同視しうるか、さらに、税務当局側も帳簿書類等の備付け状態等を確認するために社会通念上要求される程度の努力を行ったか否か、の判断にかかわるといえる。

（二）この両者は事実認定の問題とも深くかかわるが、ここでは第一審・長野地方裁判所平成五年十一月二五日判決（平成元年行ウ第九号・所得税青色申告承認取消処分請求事件）が認定した事実を前提として、以下検討する。まず、第一点についてであるが、第一審判決は次のように一般論として論じている。「そもそも青色申告制度は、納税義務者が自己の記録、保存している正確な帳簿書類を基礎として納税申告を行うことを奨励することにより、申告納税制度が適正に機能することを目的とする制度であるから、納税義務者の帳簿書類の備付け、記録又は保存が正しく行われているとともに、その点を税務当局が的確に確認できるということが、

その制度の当然の前提となっているものと考えられるところ、青色申告の承認を受けている納税義務者が正当な理由がないのに、当該帳簿書類を税務当局に提示することを拒否したような場合には、たとえ客観的には当該納税義務者の帳簿書類の備付け記録又は保存が正しく行われているとしても、税務当局がその点を確認することができない以上、やはり青色申告制度の前提自体が欠けることとなるものといわざるを得ないからである。そうすると、同法一四八条一項所定の備付け等の義務とは、ただ単に帳簿書類が存すればよいというものではなく、これに対する調査がなされた場合、税務職員においてこれを閲覧検討し、帳簿書類が青色申告の基礎としての適格性を有するものか否かを判断しうる状態にしておくことを意味し、青色申告者が右帳簿書類の調査に正当な理由なくこれに応じないため、その備付け、記録及び保存が正しく行われていることを税務署長が確認することができないときは、同法一五〇条一項一号が定める青色申告承認の取消事由に該当するものと解すべきである」（四六頁以下）。

確かに、帳簿の提示を拒否された場合には、備付け等の状況を確認できないのであるから、基本的には一項の取り消し要件を充足するものと解することができると思われる。しかし、法は取り消し要件として「不提示」そのものを明記しているわけではない。それは、課税処分のための税務調査は「社会通念上相当な範囲において税務職員の合理的な裁量」委ねられているものの、「相手方の私的利益との衡量」（最高裁第三小法廷昭和四八年七月一〇日決定、刑集二七巻七号一二〇五頁）のうえで行われねばならないので、納税者側の提示拒否を直ちに「帳簿等の備付け等の不備」と同視し得るわけではないからである。従って、提示拒否を「帳簿等の備付け等の不備」と同視するには、帳簿を提示しない納税者に正当な理由がなく、かつ、税務当局側も帳簿不提示を備付け等の義務違反と同視し得るだけの社会通念上要求される程度の努力を行ったか否か（東京地裁平成三年一月三十一日判決・判例時報一三七六号五八頁）、が問題となる。

二 本件納税者と課税当局側のトラブルの原因は税務調査において第三者の立ち会いを認めるべきかどうかの対立で、この点についての納税者の主張が帳簿提示拒否の正当な理由に該当するかも問題であるが、まず、税務当局側の第三者立ち会い拒否の姿勢及びそれに関連する本件税務職員の対応が社会通念上要求される程度の努力を行っていたといえるか、を検討しておきたい。本件の特徴は、税務職員がそれまでの当該地域の調査慣行に比べて（第一審判決も五四頁でこの事実を基本的に承認しているものと解される）かなり強硬に第三者の立ち会いを拒否し、納税者側の態度を硬化させている面があるが、この点につき、第一審判決は次のように判断している。まず、第三者立ち会いに関連して「本件の場合、古屋係官が守秘義務違反の恐れがあることを理由に立会人がいない状態でなければ調査できないとの態度を取ったことに合理性を欠く点はなく、むしろ、これに対して原告が立会人の都合が悪いことを理由に右の一月一日の調査を拒否し、その後の調査についても立ち会いの下での調査を要求し続けた以上、原告はいわれなく調査に応じなかったものと評価せざるを得ない」（五一頁）とした上で「原告は・・・いったんは帳簿書類を被告の部下職員に示したものの、たまたま仕事上の指示が必要となったため・・・伊那税務署を辞去し、その結果、被告の部下職員は、昭和六〇年分の一部及び昭和六一年分の全部の帳簿書類の記録方法の確認ができなかった。そして、その後も古

屋係官は、調査への協力を再三要請し、その間青色承認取消の可能性を三回告知したが、原告は、民商会員の立ち会いがない限り、帳簿書類の提示には応じられないとの立場を堅持し、昭和六三年一月一日に予定されていた調査も、三浦が風邪を引いていたことから、これを拒否した。右のような、古屋係官による調査の全過程を考慮すると、古屋係官は社会通念上当然に要求される程度の努力をしなかったとまでいえない。昭和六二年一二月二三日の後、本件処分までに被告の部下職員が原告宅に臨場のうえ帳簿書類の提示を求めたのが一回のみであることや、取り消しますと断定的に告知しなかったことは、右判断を左右するものとはいえない」（六〇頁）と判断している。

この判断の誤りは一般論としての第三者立ち会い拒否の理由を本件にも具体的に妥当するかをきちんと検討することなく結論を引き出している点にある。というのは、納税者は全く帳簿提示を拒否してきたわけではなく、わざわざ税務署に帳簿書類等を持参し、第三者がいては調査できないという係官の主張に譲歩しているのである。問題なのは、この段階で行われた調査が係官が主張するような第三者がいてはできないような調査であったのか、という点である。第一審判決及び平成三年四月一日付古屋正輝に対する証人調書によれば、同日古屋係官が行った調査は「部下職員二名の協力を求め、原告の同意を得て、手書きで帳簿書類を写し・・・昭和五九年分の分の売上関係の書類をすべて書き写したが、昭和六〇年分の売上関係及び経費関係の書類については一部を書き写したにとどまり、昭和六一年分に至っては何も写すことはできなかった」（第一審判決四一―四三頁）というものであり、調書によれば、「途中で中身について原告に質問するようなことがありましたか」という問いに対し「内容についてしませんでした、いくつか意味の分からないものについて質問したと思います」（質問事項五六）というものであった。このときの調査によって五九年度は青色承認取消事由がないことが判明し、本件更正も六〇年度以降の部分に限定されている。さて、このような調査が税務署係官が執拗に主張してきた第三者の立ち会いがあってはできない調査だったのであろうか。この程度の調査であれば、第三者の立ち会いがあったところで十分に可能な調査であったといわざるを得ない。要するに、本件場合は税務署係官が第三者の立ち会いを認めるべきでないという自己の立場に固執し、第三者が仮にいたとしても可能な調査に対してまで、一般的な法令違反の危険性を根拠に調査を拒否したにすぎず、社会通念上要求される程度の努力を怠っているといわざるを得ない。これに対しては、本件納税者が第三者の立ち会いを求めていたので、持参してきた機会にさし当たり必要な調査のみを行ったのであり、納税者本人により立ち入って質問する必要もでてくる、等々の反論があり得ようが、しかし、この程度の調査でも五九年度については取消事由がないことの判明は可能であったのだから、少なくとも「不提示」と「帳簿の備付け等の不備」とを同視して取り消すかどうかの判断に際しては、課税当局としてもこの程度の努力をなすべきであったといえよう。

三 右のように解すると、納税者の提示拒否に正当な理由があったかどうかを判断するまでもなく、本件青色承認取消処分は違法と解されるが、第三者の立ち会いを求めることの是非についても簡単にふれておきたい。第一審判決は「守秘義務違反」を理由に第三者の立ち会いを拒否したことに「合理性を欠く点はない」と判断しているが、一般論としてもまた本件の具体例

においても何が「守秘義務」に反することになるのかは明確ではない。納税者本人の取引にかかわる秘密であれば、本人が同意している以上立ち会いを排除する必要はないし、第三者の取引上の秘密だとすれば納税者に対しても漏らしてはならないはずなので、立会人がいるかどうかには関係ない問題となるからである。そうすると、守秘義務で保持しなければならないものは、納税者自身が知っている第三者との取引上の秘密といったものに限定されるが、このような事項を特に質問するときは立会人に出ていってもらえばよいだけであり、立ち会い一般を拒否することの合理的理由にはならないと解される。なお、税務過程において第三者の立ち会いを全く認めていないわけではなく、国税徴収法一四四、国税反則取締法六条には搜索に際しての第三者の立ち会いを規定している。これは搜索手続きが公正に行われることを担保し、処分を受ける者の利益を保護するためのものである。いずれにせよ、これらの立ち会いは当該行為が合理的に行われたかどうかの事実認定を客観化するための措置である。税務調査過程において行ないうる第三者の立ち会いというのは、税理士等が行う法的判断を含んだ陳述とは異なり（もし、第三者がそのようなことを行った場合には税理士法違反のおそれがあり、そのような立ち会いは拒否しようと思われる）、調査過程の合理性を担保するための事実認定を客観化するためのものにすぎない。確かに、前記昭和四八年最高裁判決は税務調査における税務職員の合理的な裁量を認めたが、認めたのは調査の実施方法であって、当該実施方法が合理的であったかどうかの認定方法については何も論じていないのである。一般に税務調査は密室で行われるので、税理士のような専門家がついている場合はともかく、そうでない場合は当該調査が「社会通念上相当」な範囲で行われたかどうか、通常当事者の証言しかなく、その立証はきわめて困難である。実施方法を合理的裁量に委ねるのであれば、その公正さを担保する制度的歯止めが必要であり、第三者の立ち会いというのはその意味での有益な機能を有し、従って、第三者の立ち会いを求めること自体が不合理な要求であるかのような主張は誤りであろう。具体的なケースに応じて具体的に判断すべきものであろう。

四 鑑定人の略歴及び主要著書

1 略歴

昭和二五年生まれ

昭和四八年 三月 中央大学法学部卒業

昭和五〇年 三月 一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了

昭和五〇年一二月 同博士課程中退・日本大学法学部助手

昭和五五年 四月 静岡大学人文学部法学科専任講師

昭和五五年一〇月 同 助教授

平成 四年 四月 東京大学社会科学研究所助教授併任（五年三月まで）

平成 五年 三月 法学博士（一橋大学）

平成 五年 四月 静岡大学人文学部法学科教授

平成 六年 四月 立命館大学法学部教授

2 主要著書

有斐閣『地方自治法の論点』（共著）

東大出版会『ヨーロッパの土地法制』（共著）

有斐閣『うまい酒と酒税法』（編・共著）

岩波書店『現代財政法の基本問題』（共著）

ぎょうせい『租税手続法活用事典』（平成元年度日税連研究奨励賞受賞）

ぎょうせい『転換期の開発政策』（共著）

青木書店『シミュレーション税制改革』（共著）

法律文化社『現代税法講義』（共著）

青木書店『消費税の研究』（共著）

勁草書房『現代税法と人権』

日本住宅総合センター『開発利益還元論』（共著）

その他、学術論文、判例評釈、翻訳、等多数。

以上。